

1525807-11.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/01/2022

... pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525807-11.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525807-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLIVERSON CARLOS DA SILVA XAVIER e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

CLIVERSON CARLOS DA SILVA XAVIER e JOÃO VICTOR PINHEIRO LIVINO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com art.14, inciso II, e art. 61, inciso II, "j", todos do Código Penal, e ainda pelo art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, pois, segundo apurado, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 21h53min, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Rua Copenhagen, nº 112, Lajeado, São Paulo/SP, previamente acertados e conluiados entre si e com o adolescente G.C.A., tentaram subtrair, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em pertences pessoais e um veículo pertencentes à vítima E.D.F., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os réus facilitaram a corrupção do menor de 18 anos G.C.A. (17 anos, qualificado às fls. 04), com ele praticando infração penal.

A denúncia foi recebida, os réus foram citados e notificados e apresentaram resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denuncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima E.D.F.e as testemunhas Sérgio Lemos Júnior e Jean Michel Guimarães Bezerra e ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público requereu a

procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus pelos crimes de roubo e corrupção de menores, por insuficiência de provas (art. 386, VII do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu para ambos os réus a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação da tentativa em seu máximo legal estabelecido, o afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores, a fixação de regime semiaberto, aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição dos acusados à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade delitiva comprova-se pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão do simulacro da arma de fogo, tudo isso, aliada à prova oral colhida.

A autoria também é incontestada.

A vítima E. D. F., apesar de reconhecer em juízo, apenas o réu João Victor, relatou que trabalha como UBER e que no dia dos fatos, levava um passageiro até a estação Guaianazes, e ao parar no farol, viu três indivíduos se aproximando de seu veículo. Imediatamente percebeu que seria assaltado e por isso deixou a marcha engatada e no momento em que eles anunciaram o assalto e lhe mostraram uma arma de fogo, acelerou o veículo e conseguiu sair.

Como já estavam bem próximos da estação, após deixar o passageiro em seu destino final, retornou ao local em que quase fora assaltado, à procura de uma viatura da polícia para informar a tentativa de roubo.

Assim que deu a volta no quarteirão da estação, viu que a ROCAM havia abordado os três indivíduos e de pronto os reconheceu. Assim se aproximou dos policiais e relatou o ocorrido, afirmando aos policiais que três indivíduos se aproximaram de seu veículo e anunciaram o assalto, apontando a arma em sua direção e dizendo "perdeu".

Afirmou que o "grandão" entregou a arma ao menor que saiu correndo quando viu que a vítima tinha acelerado o carro e assim conseguiu escapar da investida.

Tomou conhecimento de que a arma de fogo utilizada por um deles, fora encontrada nas proximidades e somente após os relatos dos policiais soube que se tratava de uma arma de brinquedo, pois a réplica da arma era muito perfeita.

Entre a tentativa de assalto e a abordagem dos policiais aos indivíduos se passaram menos de cinco minutos, alegou, ainda, que auxiliou os policiais a encontrar a arma utilizada pelos criminosos.

Soube apenas na delegacia de polícia, após ter feito o reconhecimento de todos os três, que um deles, era menor de idade. Em solo policial reconheceu pessoalmente Cliverson e João Victor (fls. 11/12) e o menor de idade.

No mesmo sentido das declarações da vítima, foram os depoimentos dos dois policiais ouvidos em juízo.

Sérgio Lemos Júnior, após prestar compromisso de dizer a verdade, informou judicialmente que estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de farda, quando passaram por três indivíduos que se assustaram com a aproximação da polícia. Quando olhou para trás, viu um dos indivíduos colocar a mão na cintura e jogar algo por cima de um muro, na direção de um terreno.

Diante disso, retornaram com a viatura e efetuaram a abordagem dos rapazes.

Em revista pessoal, com eles nada de ilícito foi encontrado. Indagados a respeito do que um deles havia arremessado pelo muro, eles afirmaram que se tratava de um pacote de drogas. Enquanto faziam a abordagem, um veículo branco se aproximou e o motorista relatou que os três indivíduos que estavam abordados teriam tentado roubá-lo, enquanto estava parado em um farol, na rua de cima e que eles usaram uma arma de fogo para ameaçá-lo.

Em razão disso, solicitaram auxílio policial e com a chegada de outra viatura, foi ao local em que um dos indivíduos jogou algo e localizou um simulacro de arma de

fogo.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão e encaminharam os indivíduos ao Distrito Policial para registro da ocorrência. Não conhecia os réus antes da abordagem.

Do mesmo modo, a outra testemunha e também policial militar Jean Michel Guimarães Bezerra confirmou o relato da testemunha Sérgio. Narrou em juízo que estava com seu parceiro Sérgio em patrulhamento de rotina por determinada rua, quando avistaram três indivíduos, caminhando em atitude suspeita. Resolveram retornar e abordá-los, momento em que um deles colocou a mão na cintura e jogou por cima do muro algo que parecia ser uma arma.

Em revista pessoal, não encontraram nada de ilícito, mas o parceiro da testemunha logrou êxito em localizar o simulacro que havia sido lançado por cima do muro, por um dos agentes detidos. Acrescentou, ainda, que seu parceiro foi acionado por um motorista conduzindo um veículo branco, que lhes informou que os três haviam tentado roubar seu veículo uma rua acima.

Segundo os relatos da vítima, ela estava parada em um semáforo na rua acima, quando avistou os três indivíduos vindo em sua direção que anunciaram o assalto, momento em que acelerou o veículo para fugir dos três. Comentou ainda que um deles chegou a bater com a suposta arma no retrovisor de seu carro. Ainda nas imediações, avistou os policiais fazendo a abordagem dos autores e parou para se identificar como vítima. Os indivíduos foram conduzidos ao Distrito Policial para registro da ocorrência. Não conhecia os réus antes da abordagem.

Ora, diante destes relatos, ao contrário do alegado pelo Defesa, outra solução não há que a condenação dos acusados.

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97.

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é, em regra, dependente de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

No caso em espécie a versão da vítima veio ainda confirmada pelas declarações dos policiais que viram um dos réus dispensando o simulacro de arma de fogo, que fora recuperado.

Neste ponto, salienta-se que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra os acusados.

Nesse sentido:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Além disso, os réus não foram capazes de trazer nenhum elemento de prova a corroborar o que disseram e tampouco encontraram qualquer explicação para o reconhecimento efetuado pela vítima, bem como pelo encontro da arma de fogo pelos policiais.

De fato, o réu Cliverson, em sede de interrogatório judicial, negou os fatos. Relatou que encontrou com João Victor e Guilherme na estação de metro. Afirmou que traziam consigo um pedaço de maconha que compraram na biqueira. Descendo da estação, deram de cara com os policiais militares e foram abordados. Afirma que João dispensou a maconha por baixo de um carro. Indagados sobre o que tinham dispensado, afirmaram aos policiais que era um pedaço de maconha.

Depois de uns 15 ou 20 minutos, passou um carro branco, cujo motorista falou que eles haviam tentado lhe roubar. Após a chegada de reforço policial, todos foram levados à Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pela vítima.

Não soube esclarecer o motivo pelo qual a vítima os reconheceu na Delegacia e ainda reconheceu o corréu também em juízo.

Por fim, o réu João Victor, ao ser interrogado feito em juízo, também negou os fatos. Disse que estava indo para a estação de Guaianases junto com Cliverson e Guilherme e avistaram uma viatura da ROCAM. Estava com maconha no bolso e como tem passagem por tráfico, ficou com medo de ser preso e arremessou a droga por um portão.

Logo em seguida, foram abordados, e os policiais perguntaram o que ele tinha arremessado no terreno, sendo que de pronto disse que eram drogas. No momento em que estavam sendo abordados, apareceu um rapaz num veículo branco afirmando que eles haviam tentado roubá-lo. Os policiais algemaram eles e os levaram para a delegacia. Não tem conhecimento de que os policiais localizaram uma arma no local onde dispensou as drogas. Não chegou a vê-la. Além de ter praticado ato infracional equiparado ao crime de tráfico, teve passagem na vara da infância também por um roubo.

Por fim, não soube afirmar o motivo pelo qual a vítima o reconheceu tanto em juízo como em sede policial e afirmou que conhecia Cliverson e Guilherme do bairro onde todos moram.

Note-se ademais que o concurso de pessoas também veio devidamente comprovado nos autos, seja pela análise das provas nos autos e ainda pela narrativa da vítima e das testemunhas. Com efeito, já se pacificou que para a caracterização do concurso de pessoas não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos.

É coautor o agente que, durante a execução do roubo, permanece em companhia de

executores prima facie mais dinâmicos, ou mais agressivos, ou mais audazes, seja por encorajar os comparsas com sua presença, seja por oferecer-se como soldado de reserva, e, no caso, auxiliando a remoção segura do objeto subtraído. Também configurado no caso em tela, o crime previsto no art. 244- B, do Estatuto da Criança e Adolescente.

Com efeito, é pacífico que simples de fato de se cometer crimes com crianças ou adolescentes, que estão em situação de formação de caráter, já é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 244- B do ECA, pouco importando se a pessoa protegida já tenha se enveredado em outras oportunidades na prática de atos infracionais, já que necessita de cuidado e proteção integral no sentido de que não tenha como modelos de vida pessoas maiores de idade que cometem crimes.

Veja-se que a Lei nº 8.069/90 tem como escopo a proteção integral das crianças e dos adolescentes com absoluta prioridade, nos exatos termos do que dispõe o art. 277 da Carta Magna.

Tal entendimento, aliás foi consolidado pela Sum. nº 500, do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: "A configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova de efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Caracterizadas, portanto, as infrações penais de roubo e corrupção de menores, passo a dosimetria da pena.

1) CLIVERSON CARLOS DA SILVA XAVIER

1.1) Do crime de roubo agravado

O réu é reincidente, já tendo sido condenado perante a 20ª Vara Criminal da Capital (Autos nº 1511262-33.2021.8.26.0228 da 20ª Vara Criminal de São Paulo) fato este que será devidamente considerado na segunda fase da dosimetria da pena.

Por outro lado, não possui outras condenações e assim lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena base ser fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, além da reincidência acima apontada, há que se ressaltar que o crime também foi cometido em situação de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/5, perfazendo 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Neste ponto, não obstante posicionamento em contrário, para esta magistrada o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação

Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020: “O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença”, escreveu o magistrado em seu voto. “De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.”

No mesmo entendimento: Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander: “O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), “a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda”

STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello: "Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade.

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020) TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexistência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020). Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

É o caso, ainda de se reconhecer a atenuante da menoridade, já que, conforme fls. 16, o réu era menor de 21 anos na data do crime.

Assim sendo a pena deve retornar ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase de aplicação de pena presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, uma vez que restou-se comprovado nos autos que o acusado agiu em concurso de agentes e diante disso a pena deve ser aumentada no mínimo legal de 1/3, chegando-se a 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Há ainda que se reconhecer a tentativa e considerando o iter criminis praticado pelo autor que juntamente com seus comparsas, anunciaram o roubo munidos de um simulacro de arma de fogo, crime este que somente não se consumou porque a vítima conseguiu acelerar seu veículo e assim escapar da abordagem, a pena deve ser diminuída pela metade, totalizando 2 anos, 8 meses de reclusão e 06 dias-multa. 2.2) Do crime previsto no art. 244-B do ECA

O réu é reincidente, como acima apontado, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação da pena.

No mais lhe favorecem as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal assim sendo a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecidas as agravantes da reincidência e ainda a relativa ao estado de calamidade pública, pelos fundamentos acima expostos, a pena deve ser aumentada em mais 1/5, chegando-se a 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão.

Também presente no caso a atenuante da menoridade e assim sendo a pena deve ser diminuída em 1/6, e retornar ao patamar mínimo legal estabelecido de 01 ano de reclusão.

Na terceira fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Considerando que os crimes foram cometidos mediante uma só ação, é o caso ainda de se reconhecer o concurso formal de delitos e desse modo a pena do crime mais grave deve ser aumentada em mais 1/6, nos exatos termos do que dispõe o art. 70, "caput" do Código Penal, devendo assim a pena final ser fixada em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 07 dias -multa.

## 2) JOÃO VICTOR PINHEIRO LIVINO

### 2.1) Do crime de roubo agravado

O réu é reincidente, já tendo sido definitivamente condenado nos autos nº 0091419-58.2017.8.26.0050, perante a 20ª Vara Criminal Central de São Paulo, (fls. 66), o que será levado em conta na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, foi também condenado definitivamente nos Autos nº 1500312-50.2020.8.26.0599, perante a 2ª Vara Criminal de Piracicaba. Assim, sendo diante dos maus antecedentes atestados, forçoso reconhecer que não lhe favorecem as circunstâncias previstas no art. 59 do Penal, devendo a pena base ser aumentada em 1/6, totalizando 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Já na segunda fase da dosimetria da pena, deve-se considerar a agravante da reincidência, acima apontada, bem como que o crime foi cometido em situação de calamidade pública, consoante ampla fundamentação acima já exposta, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/5, perfazendo 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase, há que se considerar a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, uma vez que restou-se comprovado nos autos que o acusado agiu em concurso de agentes. Aumento, assim, a pena em 1/3 (um terço) restando 7 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Presente no caso também a tentativa e diante do iter criminis percorrido pelo agente a pena deve ser diminuída pela metade, chegando-se a um total de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e 08 dias-multa.

### 2.2) Do crime previsto no art. 244-B do ECA

O réu é reincidente, como já acima apontado, o que será considerado na segunda fase de aplicação de pena, por outro lado, a pena deve ser aumentada em 1/6 em razão de sua outra condenação, chegando-se a 01 ano e 2 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a pena deve ser agravada em mais 1/5 diante da reincidência e da agravante da pandemia, como acima já explanado, totalizando 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Na terceira fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Considerando que os dois crimes aqui praticados foram cometidos em concurso formal, (art. 70, "caput" do Código Penal) a pena do crime mais grave será aumentada em 1/6, perfazendo 04 anos, 04 meses e 08 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de condenar os réus como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso formal com o art. 244-B, da Lei 8.069/90, aplicando-se ao réu CLIVERSON CARLOS DA SILVA XAVIER a pena de 03 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão e 08 dias-multa, e ao réu JOÃO VICTOR PINHEIRO LIVINO a pena 04 anos, 04 meses e 08 dias de reclusão e 10 dias-multa fixada no valor mínimo legal, já que não nos autos provas da situação financeira dos acusados.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, para ambos os acusados que são reincidentes e mesmo tendo sido condenados, após serem soltos, novamente se colocaram a praticar crime, demonstrando que a eles somente o cárcere lhes é suficiente.

Tal fato, apenas têm o condão reforçar o posicionamento desta magistrada para quem, na grande maioria dos casos de roubo, este é o único regime a ser aplicado, já que é inegável a periculosidade e ousadia de quem se põe a praticar assaltos, pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social.

Não se pode esquecer que "O roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo" (JUTACrim 88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não

pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias'' (RTJ 123/547).

Deixo de computar o período de prisão provisória dos réus para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente em critério objetivo. Depende, também, do mérito do condenado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos parte de sua pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Além disso, prevalecer o entendimento de que a lei não determina o cômputo do período de prisão provisória como meio de antecipar a progressão de regime, mas como critério para fixar o regime inicial de cumprimento da pena, aquele que sob custódia esteve no curso do processo poderá ser agraciado com progressão, na fase de execução criminal, com novo desconto do período já considerado para beneficiá-lo com regime menos gravoso na sentença condenatória.

Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2º do CPP, a teor do que vem decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.

O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2º do Código Penal.

No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina o artigo 33 §§ 2º. e 3º do Código Penal.

É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime.

A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2º, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 805/806).

Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.

DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2º, do CPP.” (AgRg no HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, Dje 03/06/2019).

“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)” .(HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, Dje 10/04/2019).

Outrossim, levando em conta que o crime foi praticado mediante violência, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o inciso I do art. 44 do Código Penal.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, pois remanesçam os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, e para a garantia da aplicação da lei penal.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo presos, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar dos acusados que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após o trânsito em julgado, retifique-se a guia de execução, se necessário e elabore-se o cálculo da pena da multa imposta ao réu.

Oficiem-se aos IIRGD e o TRE.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA